Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55) 3412-1410 - Email: fruruguaia1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5003013-14.2021.8.21.0037/RS

AUTOR: ANA LUCIA RAMIRES BARBOSA
ADVOGADO: ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA (DPE)
ADVOGADO: CRISTIANO VIEIRA HEERDT (DPE)

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I – RELATÓRIO:

ANA LUCIA RAMIRES BARBOSA ajuizou ação de obrigação de fazer em face de **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, ambos qualificados nos autos. Relatou ser portadora de melanoma maligno de pele (CID 10 C43), necessitando de uso do fármaco PEMBROLIZUMABE 200MG, duas ampolas a cada vinte e um dias, cujo custo orçado para o período de três meses perfaz a quantia de R$ 146.342,40 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Discorreu sobre o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de garanti-lo. Diante do exposto, requereu, em juízo de cognição sumária, e ao final, o fornecimento do tratamento postulado. Pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. Instruiu a inicial com documentos.

Determinada a inclusão da União no polo passivo (evento 04), foi interposto agravo de instrumento pela parte autora ao qual foi dado provimento (eventos 06 e 09).

Concedidos à parte autora o benefício da gratuidade de justiça e a tutela de urgência pleiteada (evento 11).

Citado, o demandado apresentou contestação (evento 20). Teceu considerações sobre o efeito vinculante das teses fixadas pelos Tribunais Superiores para a matéria de saúde e a necessidade de observação no caso concreto. Discorreu sobre a necessidade de observância da repartição de competências, nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, sendo a União o ente responsável pelo financiamento de medicamento oncológico. Enfatizou a necessidade de emenda à inicial, com a citação da União, com a consequente extinção do processo e remessa dos autos à Justiça Federal para processamento e julgamento. Defendeu não ser possível o fornecimento de medicamento sem necessidade comprovada. Frisou que o Estado não pode ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento não disponibilizado no âmbito da Saúde Pública, sobretudo quando a prestação de saúde requerida é de alto custo. Dissertou sobre a política nacional de prevenção e controle do câncer e da possibilidade de acesso ao tratamento no Sistema Único de Saúde, por meio dos CACONs/UNACONs. Sustentou a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários ao FADEP. Requereu o acolhimento da prefacial e a inclusão da União no polo passivo da ação e, no mérito, a improcedência do pedido, ou, em caso de procedência, seja utilizada a denominação comum brasileira do medicamento.

Houve réplica (evento 23).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (evento 30).

As partes não demonstraram interesse na produção de outras provas (eventos 64 e 66).

Comprovada a indisponibilidade do fármaco, foram deferidos pedidos de bloqueio de valores para aquisições (evento 43 e 78), cujas prestações de contas se encontram nos eventos 55 e 91, em relação às quais não se opôs o requerido (eventos 58 e 99).

A seguir, vieram conclusos para julgamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

O feito comporta julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por tratar de matéria que prescinde de produção de prova em audiência para a solução das questões controvertidas.

Da inclusão da União com remessa à Justiça Federal.

Pretende a parte demandada, em preliminar de contestação, a emenda da inicial, com a inclusão da União no polo passivo, e a consequente extinção do processo e remessa dos autos à Justiça Federal para processamento e julgamento.

Contudo, conquanto este também seja o entendimento desta Magistrada, a questão foi enfrentada em sede de agravo de instrumento (evento 09), no qual restou afastada a aplicação da tese fixada no Tema 793 do STF na parte do redirecionamento à União.

Assim, afasta-se a prefacial.

Mérito.

É certo que a Constituição da República, no artigo 2º, consagra a independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assegurando, dessa forma, a atuação independente de cada Poder livre da interferência dos demais.

Entretanto, mais adiante, essa mesma Constituição contempla a cláusula da inafastabilidade do controle jurisdicional no inciso XXXV do artigo 5º.

Por conseguinte, esses dois preceitos conciliam-se quando se condiciona a interferência do Poder Judiciário nos demais Poderes à existência de uma lesão ou de uma ameaça de lesão a um direito subjetivo perpetrada pelo Executivo ou Legislativo.

O direito à saúde, invocado pela parte autora, com o ajuizamento da presente ação foi erigido à condição de direito fundamental pela Constituição da República ao prevê-lo, de forma expressa, no rol dos direitos sociais no artigo 6º.

Ademais, a Constituição da República no artigo 196 explicita que: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Dessa forma, a negativa de fornecimento de medicamentos necessários à saúde e, por consequência, à vida do paciente, mormente para aqueles sem condições econômicas de adquiri-los configura inequívoca violação ao direito fundamental à saúde, razão pela qual se justifica a intervenção do Poder Judiciário a fim de examinar a alegação de violação a direito subjetivo pelo Executivo.

Na hipótese dos autos, a parte autora encartou atestados médicos acostados, no documento 02 do evento 01, que demonstram a moléstia que a acomete com a prescrição, pelo médico que a examinou e acompanha a evolução da doença, do medicamento pleiteado.

Da mesma forma, a negativa do Estado no fornecimento dos fármacos além de constituir fato público e notório, restou demonstrada nos autos porquanto previamente a cada bloqueio de valores efetivado foi realizada consulta ao sistema AME para constatar a alegada omissão.

Com relação ao argumento declinado pelo réu quanto à ausência de submissão da parte autora à política pública para tratamento oncológico nos CACONS disponíveis na rede pública de saúde, sublinho que **incumbe ao próprio réu promover esse encaminhamento**, sob pena de ser compelido a arcar com os custos decorrentes da sua omissão na tutela do direito fundamental à saúde.

Nesse sentido:

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. XTANDI 40MG (ENZALUTAMIDA). 1. Sobre o argumento de que deveria ser suspenso o recurso em razão do trâmite do REsp. nº 1.657.156/RJ pelo rito dos recursos repetitivos, apesar de configurar inovação recursal, nada obsta que a suspensão se dê em momento posterior, ou seja, em eventual admissibilidade de Recurso Especial ou Extraordinario, situação em que, caso seja favorável a decisão do Tribunal Superior, por certo retornará a este Relator para Juízo de Retratação. Não há falar em nulidade da sentença hostilizada por não suspender o trâmite do processo. A prestação jurisdicional seria nenhuma se tivesse que aguardar o julgamento do recurso repetitivo. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema nº 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 6º, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal. Não se está aqui a contrariar os princípios da separação dos Poderes, da reserva do possível, da igualdade, da isonomia e da universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à saúde e à dignidade (artigos 1º, III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal). 3 O atestado médico do profissional devidamente habilitado que acompanha o tratamento da parte autora constitui prova suficiente para embasar a pretensão desta, bem como a adequação do tratamento prescrito para a doença que a acomete. O entendimento do referido profissional somente pode ser afastado por prova robusta, o que não se verifica ter ocorrido nos autos. 4. Comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, **é dever dos entes públicos encaminhá-la ao CACON/UNACON** para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de saúde e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF.* ***Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.*** *REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076504273, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 26/06/2018) (grifei)*

Transcrevo elucidativo trecho desse precedente:

" (...)

Com base na legislação supra, conclui-se que é competência dos CACONs/UNACONs o fornecimento de tratamento de câncer, como, a exemplo do caso posto em liça, fornecimento de medicamento oncológico.

No entanto, compete aos entes públicos assegurar que o medicamento postulado para o tratamento seja entregue à parte autora através dos centros/unidades especializados no tratamento do câncer mais próximo de sua residência. Em hipótese do não fornecimento imediato pelo referido Centro, caberá aos réus providenciá-lo. Nesse sentido são as reiteradas decisões emanadas por esta Câmara, in verbis:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. ***Responsabilidade pelo fornecimento de tratamento para o câncer. Reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação de serviços de saúde, não há qualquer impedimento ao cidadão em pleitear tratamento ou medicação a qualquer ente da Federação. Compete a estes, pois, a responsabilidade - sob pena de arcar com os custos do tratamento -, diligenciar no encaminhamento e internação do paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON). Substituição do medicamento.*** *A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento ao paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para improcedência da alegação de que os fármacos requeridos não seriam indicados para o quadro clinico da parte autora, bem*

*como para desautorizar a pretensão de substituí-los com base em conclusões obtidas sem estudo do caso concreto. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70064648496, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em **24/06/2015**)*

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA CÂNCER. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, inexistindo a pretendida ordem na busca dos serviços e ações. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos no funcionamento do Sistema Único de Saúde. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Fracionário. **ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DO CÂNCER. Caso concreto que abre ensejo a oportunizar ao agravante encaminhar a paciente aos Centros de Alta Complexidade Oncológica (CACON ou UNACON), antes que se lhe ordene o fornecimento do tratamento. Conservada sua responsabilidade subsidiária e solidária em caso de omissão ou insuficiência da providência.** DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70062146311, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em **25/03/2015**) [grifei]*

Destarte, descabida a justificativa de que ao Estado compete apenas a fiscalização e o repasse da verba destinada pela União aos estabelecimentos habilitados, eis que ausente responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos afetos à área de oncologia, uma vez que o respeito pelo ser humano deve se dar em todas as fases de sua vida.

A verossimilhança vem corroborar as alegações da parte autora, porquanto consubstanciada no entendimento desta Corte, de que é direito do cidadão e dever inquestionável do ente público o fornecimento de aparelhos/medicamentos de difícil acesso e caros àqueles que dele necessitem para tratamento de combate a neoplasias e que não tem condições financeiras de adquiri-los por meios próprios nos termos dos artigos 5º, caput, 6º, 196 e 203 da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 9.908/93.

Em assim sendo, a parte apelante deverá adotar as medidas administrativas necessárias (encaminhamento) para que a parte apelada receba o tratamento recomendado junto ao CACON ou UNACON mais próximo de sua residência, no prazo de 05 dias. Na eventual hipótese de lá não ser imediatamente realizado o tratamento, caberá ao réu o custeio do tratamento necessitado, inclusive com a possibilidade de bloqueio de valores a ser realizado pelo Julgador a quo."

Nesse sentido, diante dos atestados médicos acostados no documento 02 do evento 01, que demonstram a moléstia que acomete o demandante e prescrevem o tratamento, impõe-se o reconhecimento do dever do réu de assegurar o tratamento médico postulado na inicial, podendo providenciar o encaminhamento da parte autora para que receba o tratamento recomendado junto ao CACON ou UNACON mais próximo de sua residência, sob pena de custeio do tratamento necessitado, mediante bloqueio de valores.

Por fim, no tocante à prescrição do medicamento conforme a "Denominação Comum Brasileira", tratando-se de mesmo princípio ativo, poderá ser substituído pelo correspondente genérico, a ser fornecido pelo demandado, para fins de redução de custos.

Isso porque, havendo medicamento genérico, de regra menos oneroso que o nome comercial, pode o Poder Público fornecê-lo em atenção ao princípio da economicidade, que exige a redução do sacrifício imposto à coletividade.

III – DISPOSITIVO:

Em face do exposto, na forma do artigo 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **ANA LUCIA RAMIRES BARBOSA** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** para tornar definitiva a liminar deferida e determinar ao requerido que providencie o encaminhamento da parte autora para que receba o tratamento recomendado com o medicamento PEMBROLIZUMABE 200MG, junto ao CACON ou UNACON mais próximo de sua residência, sob pena de custeio do tratamento necessitado, mediante bloqueio de valores.

Isento o Estado do pagamento da taxa única (art. 5°, inc. I da Lei nº 14.634/2014). Condeno-o ao pagamento integral das despesas processuais (arts. 14 e 16 da Lei nº 14.634/2014) exceto condução do Oficial de Justiça, se houver (Ofício Circular nº 03/2014- CGJ).

Caso a parte vencedora tenha antecipado taxa única e despesas, o ente público deverá reembolsar estes valores da seguinte forma (Lei n° 14.634/2014, art. 5º, parágrafo único, parte final):

a) com correção pelo IPCA-E (admitida a deflação, preservado o valor nominal, conforme o Tema n° 678 do STJ) a contar da data de cada desembolso;

b) com juros moratórios à taxa aplicada à caderneta de poupança (art. 12, inc. II da Lei Federal n° 8.177/1991), a contar do trânsito em julgado desta decisão.

Incabível, outrossim, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da do Enunciado de nº 421 da Súmula do STJ, porquanto resta configurada a confusão entre credor e devedor no caso.

Publicação, registro e intimações já agendados eletronicamente.

Dispenso o reexame necessário, com fundamento no §4º do artigo 496 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria foi, inúmeras vezes, objeto de julgamentos realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, há reiteradas decisões do Tribunal de Justiça gaúcho – a título de exemplo: Apelação e Reexame nº 70054040787; Apelação e Reexame nº 70059201640; Reexame Necessário nº 70056222516.

Em caso de interposição de **apelação**, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2º, do CPC.

Após, ao Ministério Público.

A seguir, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Com retorno dos autos, intimem-se as partes e/ou transitada em julgado a presente decisão, nada sendo requerido, recolhidas eventuais custas pendentes ou adotadas as providências para sua cobrança administrativa, **arquivem-se.**

Documento assinado eletronicamente por **RAMIÉLI MAGALHÃES SIQUEIRA, Juíza de Direito**, em 4/3/2022, às 15:6:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10014421107v9** e o código CRC **9145fccb**.